



论生态损害救济的模式选择

刘 静*

内容提要 围绕着环境民事公益诉讼和生态环境损害赔偿诉讼,我国建立了私法主导的生态损害救济体系。这一体系在发展环境法治的同时,也带来了相关主体角色错位、政府主导的修复和司法判决难以衔接以及法院主导修复能力有限等问题。而生态损害的公法救济在现行立法中未得到足够重视。影响生态损害救济模式选择的主要因素有:法律体系对公私法划分的影响;行政机关在救济生态损害方面的权能和保障以及私法救济的困难程度。基于这些因素的考量,我国应通过立法授权、行政执行能力的强化和行政公益诉讼制度的完善,建立公法主导的生态损害救济制度。私法救济在公法框架建立前或无法适用的情况下,可发挥补充作用。

关键词 生态损害 救济模式 公法救济 环境公益诉讼

严重污染事件的频发使得生态损害在世界范围内广受关注。围绕着生态损害的救济,各国发展出两种常见的应对模式:第一,公法模式,即对污染者和其他责任人课以预防损害发生及扩大和修复环境的义务,并以行政强制或行政处罚来保障修复的实现。第二,私法模式,即政府或其他组织并不先行诉诸行政义务体系,而是直接对污染者提起民事诉讼,要求后者采取修复措施或提供赔偿。虽然一国生态损害救济体系常常混合了两者,但在不同的法律传统和制度背景之下,公、私法模式所占比重差异很大。

我国以环境民事公益诉讼和生态环境损害赔偿诉讼为核心发展出了一套私法主导的生态损害救济体系。该体系的建立对环境保护和法治发展具有重要意义。但是,通过以解决私益纠纷为基础建立的侵权法来救济指向公益损失的生态损害,在损害本身的可赔偿性、损害评估、救济方式以及求偿主体的确定等方面都存在重大障碍,^①而且保

* 武汉大学环境法研究所副教授。本文系国家社科基金项目“环境治理工具的互动与整合研究”(项目批准号:17CFX040)的阶段性成果。

① 参见徐祥民、邓一峰:《环境侵权与环境侵害——兼论环境法的使命》,载《法学论坛》2006年第2期;吕忠梅:《环境侵权的遗传与变异——论环境侵害的制度演进》,载《吉林大学社会科学学报》2010年第1期;吕忠梅:《“生态环境损害赔偿”的法律辨析》,载《法学论坛》2017年第3期。



护公共利益通常被认为是行政权的根本任务。^②通过公法对生态损害进行救济可以发挥行政机关的专业性、灵活性和高效性之优势。虽然行政主导的修复在我国实践中并不鲜见,但其在理论研究和立法中还未得到重视。这导致了公私法行为的衔接困难、相关主体在生态损害救济中角色错位等问题。我国生态损害救济体系到底应以私法还是公法为主导,应如何进行具体的制度设计成为理论和实践中必须面对的重要问题。为回答这一问题,本文先简要介绍我国生态损害救济制度的发展过程并评析私法主导的救济模式面临的挑战。第二部分以荷兰和美国为例介绍生态损害救济的公、私法模式的具体运行方式,并比较其异同,分析影响模式选择的因素。第三部分基于此因素分析我国国情,阐释我国建立公法主导的生态损害救济体系的合理性。第四部分为具体制度的构建提供建议。

一、我国生态损害救济制度面临的挑战

我国立法和学术研究对生态损害救济的关注是从借鉴域外经验开始的。美国《综合环境反应、赔偿和责任法》(CERCLA)、《石油污染法》下的自然资源损害赔偿制度,^③以及欧盟 2004 年颁布的《环境责任指令》(Environmental Liability Directive,以下简称《指令》)及其实施广受关注,^④这些制度为我国的制度建设提供了范本。美国救济体系体现出典型的私法主导特点,行政机关不通过行使行政权迫使相对人采取修复措施,而是自行评估乃至组织修复后,就相关费用通过民事诉讼索赔。欧盟《指令》主要是对预防和修复义务的规范,体现出更强的公法性质。^⑤但其在标题上使用了多有私法指向的“环境责任”(environmental liability)一词,且在具体制度设计上涉及费用求偿、类似严格或过错责任、免责条款、多主体的责任分担、诉讼时效等相关安排。^⑥这些用语和条款都与侵权责任的构造异曲同工,甚至掩盖了《指令》本身的公法特色。这些蓝本的特点使得我国在制度借鉴过程中更为关注如何拓展侵权法的适用范围以救济生态损害,而非建立与完善公法框架。

立法对私法手段的关注体现在两个方面:通过《民事诉讼法》和《环境保护法》的修改引入了环境民事公益诉讼以及通过《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》及《生态

② 参见[日]南博方:《行政法》(第6版),杨建顺译,中国人民大学出版社2009年版,第5页;王明远:《论我国环境公益诉讼的发展方向——基于行政权与司法权关系理论的分析》,载《中国法学》2016年第1期。

③ 参见王树义、刘静:《美国自然资源损害赔偿制度探析》,载《法学评论》2009年第1期;任世丹:《美国的生态损害赔偿制度》,载《世界环境》2010年第3期;于文轩:《美国水污染损害评估法治及其借鉴》,载《中国政法大学学报》2017年第1期。

④ 参见蔡守秋、海燕:《也谈对环境的损害——欧盟〈预防和补救环境损害的环境责任指令〉的启示》,载《河南省政法管理干部学院学报》2005年第3期;竺效:《生态损害综合预防和救济法律机制研究》,法律出版社2016年版。

⑤ See Gerd Winter, Jan H. Hans & Richard Macrory et al, *Weighning up the EC Environmental Liability Directive*, 20 J. Env. L. 163, 167 (2008).

⑥ See Environmental Liability Directive, art. 3, 4, 8, 9, 10.

《环境损害赔偿制度改革方案》的颁布引入了生态环境损害赔偿诉讼。本文以生态损害诉讼指代所有请求修复生态环境或赔偿生态损害的民事诉讼,即包含上述两种诉讼。相关法律文件在用语和制度的构建上都采用了民事诉讼主导的方式。常与侵权责任相联系的“生态环境损害赔偿”一词涵盖对生态损害的评估、修复和求偿程序。在具体的制度构建上,政府、有关组织和检察院被授权向法院起诉,要求责任人对生态损害进行修复或就相关费用进行赔偿。且文件未要求相关主体在提起生态环境损害赔偿诉讼或民事公益诉讼前穷尽行政程序。相对于集中的私法规范,我国并未建立综合性的生态损害预防与修复的公法义务体系,仅在一些环境单行法中零星规定了主管机关可在特定情形下作出责令改正、消除污染或代履行等命令的权限。

就实践层面而言,生态环境损害赔偿诉讼开展较晚,环境民事公益诉讼的经验则较为丰富。多数民事公益诉讼案件都涉及生态修复或赔偿要求。^⑦然而私法主导的救济方式在达成修复环境的目标上存在效果不彰的问题,主要体现在以下方面:案件救济以损害赔偿及支付修复费用为主,而较少要求进行实际修复;^⑧即使要求进行修复,常表现为缺乏适当履行方式的“空判”;^⑨判决执行困难或执行周期过长。^⑩私法救济效果的局限主要与以下因素有关。第一,法院在认定生态损害事实、决定救济方式、监管修复行为和赔偿金使用方面的专业性都存在不足;^⑪第二,政府虽然在生态环境损害的识别、取证和组织、监督修复行动等方面具有专业性,然而实践中社会组织和检察院是主要的起诉主体,政府表现相对消极。甚至发生过因为法院受理非政府组织的起诉,负有监管职责的行政机关对污染破坏问题不予处理,消极等待审理结果的情况。^⑫即使在政府提起诉

⑦ 参见巩固:《2015年中国环境民事公益诉讼的实证分析》,载《法学》2016年第9期;张忠民:《环境公益诉讼被告的局限及其克服》,载《环球法律评论》2016年第5期。

⑧ 笔者从我国三大案例数据库“中国裁判文书网”“北大法宝”和“无讼搜索”收集了从2014年至2018年10月31日118起涉及生态损害赔偿或修复请求的环境民事公益诉讼和生态环境损害赔偿诉讼的法律文书。其中仅有13起污染案件,21起生态破坏案件要求采取实际修复措施。

⑨ 上述要求采取修复措施的13起污染案件中,多为笼统要求修复,仅少部分判决明确了修复目的或方式。生态破坏案件中的救济形式主要体现为补种和养护林木、增殖放流等,重在从数量上恢复直接被非法砍伐或捕捞的林木和鱼类,而非全面恢复受损的生态服务功能。此外,实践案例还存在仅针对个别环境介质修复而缺乏系统性考量、忽视环境修复的长期性等问题,难以实现有效修复。参见吕忠梅、窦海阳:《修复生态环境责任的实证解析》,载《法学研究》2017年第3期。

⑩ 参见石春雷:《论环境民事公益诉讼中的生态环境修复——兼评最高人民法院司法解释相关规定的合理性》,载《郑州大学学报》(哲学社会科学版)2017年第2期。

⑪ 参见胡静:《环保组织提起的公益诉讼之功能定位——兼评我国环境公益诉讼的司法解释》,载《法学评论》2016年第4期。

⑫ 如“中国生物多样性保护与绿色发展基金会诉浙江富邦集团有限公司案”中,环保组织提起公益诉讼后,受理法院书面通知对涉案问题有监管权的环保部门,但该部门未作回应,也未采取应对措施。参见浙江省嘉兴市中级人民法院(2015)浙嘉民初字第7号民事判决书。

讼的场合,往往也未在起诉前穷尽行政手段,存在行政职权民事化的嫌疑。^⑬第三,当司法与行政程序并存时,环保组织、行政机关、司法机关可能就损害的存在及程度、修复方案的选择等事项存在争议,难以协调。如“常州毒地案”中,环保组织认为政府组织的修复未能有效控制风险,从而要求污染者承担修复责任。事实上,由于政府组织的修复行为不能定性为民事行为,针对其是否达到有效控制风险、恢复受损公益的目的,法官很难在民事判决中作出判断。即使法院支持环保组织的请求,要求污染企业承担新的修复责任,也会产生法院判决和政府修复行为如何协调的问题。

上述困境,诚然可以通过完善生态损害赔偿的求偿主体范围、构建生态损害修复的标准和费用管理机制等具体制度安排来予以改善。但究其根本,在于未能实现政府主导的修复与司法干预下的损害赔偿的合理定位及其良好衔接。本文将探讨公法和私法主导的两种生态损害救济模式,对比其异同点,并结合我国的实际情况,为制度模式的选择提供建议。

二、生态损害救济的公、私法模式及其异同

生态损害救济的公、私法模式下,污染者、政府、其他组织分别扮演怎样的角色,行政与司法程序如何协调等问题需通过分析具体实例来展现。将抽象的模式具体化,并比较其异同点,便于理解为何各国在救济体系的构建中选择了不同道路。总结影响模式选择的因素,也可为我国的模式选择和制度完善提供指导。

本文选取两种救济体系作为研究对象:欧盟《指令》及美国的自然资源损害赔偿制度。这两种体系是我国制度建设和理论准备过程中的范本,也是目前各国生态损害救济中经验较多、较为成熟的制度。《指令》的适用需要成员国的转化,其运作在成员国间存在较大差异。荷兰是一个典型的大陆法国家,在《指令》制定之前,国内就有生态损害救济的公法框架,私法下也存在着救济部分生态损害的可能。《指令》的转化更强化了公法的作用。本文将以此荷兰为例介绍公法主导下的生态损害救济制度。

美国生态损害赔偿制度则更多体现了私法的重要性。值得注意的是,近年来法国法下生态损害救济的私法路径也引起了学界的关注。在一定范围内,法国法下的环保组织可提起生态损害诉讼。但在早年的诉讼中,纯环境损失(生态损害)未被直接认定为可赔偿的损失,而往往通过精神损害,即环保组织的慈善目的、名誉甚至其成员感情

^⑬ 如重庆市第一中级人民法院(2017)渝01民初773号民事判决书和江苏省南京市中级人民法院(2016)苏01民初1203号民事判决书都涉及了水污染事件。根据《水污染防治法》第85条,环保部门还可以责令被告限期采取治理措施,消除污染或代履行,通过行政手段救济生态损害。但两案例中,环保部门都未采取该措施,而直接由政府 and 环保组织提起生态损害赔偿诉讼。

的损失得到救济。^⑭该赔偿不能真实地反映生态损害的特征和程度。^⑮《指令》生效后,法国通过修改《环境法典》《行政司法法典》《刑事诉讼法典》予以转化,建立起生态损害预防与救济的行政规制体系,并通过行政与刑事责任予以保障。^⑯此外,受“Erika案”影响,法国于2016年发布了一项新的法令,以修改民法典,将生态损害纳入民事赔偿的范围,并大大扩张了起诉主体资格。^⑰但该法刚刚修订,私法救济在实践中将如何展开,其效果如何,私法模式与现有生态损害救济的行政规制手段如何衔接还缺乏具体的规则。^⑱另外,无论是《指令》下的公法路径,还是民法典下新的生态损害诉讼都缺乏相应的实例。^⑲因为立法历史较短和实践经验不足,无法勾勒出法国生态损害救济制度的全貌,了解其具体运作方式,尤其无法断定私法路径是否能替代公法路径在对环境损害的预防和救济中居于主要地位。故而本文未将法国列入重点比较研究的对象。

(一) 公法主导下的生态损害预防与修复

早期民法为荷兰生态损害提供了一定程度的救济。民法就损害赔偿和禁令设置了不同的构成要件,也形成了救济生态损害的不同障碍。荷兰《民法典》第6编规定了损害赔偿的基本构成,并将可赔偿的损害限制为物质损失和其他法律界定可赔偿的损失。非物质损失则需要法律的规定,并受《民法典》列举范围的限制。^⑳这就意味着出现生态损害时,公共机构或环保组织支出的预防和修复措施的费用可作为物质损失得到赔偿。^㉑除此之外的生态损害很难纳入可赔偿的非物质损失范畴。禁令因不以损害为构成要件,为生态损害的救济提供了更多可能。^㉒但禁令体现为对被告为或不为一定行为的要求,通常涉及停止排放,采取减排措施等。^㉓其与生态修复有着较大的区别,意在解除紧迫的威胁,防止损害的发生、持续或扩大,而非使受损的利益得到全面的恢复。此外,公共机构寻求禁令救济不可对公法的实施造成妨碍,即仅在公法尚未对某种行为进行规范的时候,提供一种损害救济的途径。^㉔

^⑭ See Danai Papadopoulou, *The Role of French Environmental Associations in Civil Liability for Environmental Harm: Courtesy of Erika*, 21 J. Env. L. 87, 98 (2009).

^⑮ See Simon Taylor, *Extending the Frontiers of Tort Law: Liability for Ecological Harm in the French Civil Code*, 9 J. Eur. Tort L. 81, 90 (2018).

^⑯ 参见竺效:《论生态损害综合预防与救济的立法路径——以法国民法典侵权责任条款修改法案为借鉴》,载《比较法研究》2016年第3期。

^⑰ See Law no. 2016-1087 of 2016., French Civil Code, art. 1246-1252.

^⑱ See Simon Taylor, *supra* note 15, 94-95.

^⑲ 《环境责任指令》主要受限于其狭窄的适用范围。See European Commission, *Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Environmental Liability with regard to Prevention and Remedying of Environmental Damage*, COM (2016) 204 final. 民事案例的缺乏则因为民法典较短的修改历史。

^⑳ Zie Burgerlijk Wetboek, art. 6:95, 6:106, 6:162 (1).

^㉑ See Michiel Heldeweg & René Seerden, *Environmental Law in the Netherlands*, at 498 (Kluwer Law International, 2012).

^㉒ See Gerrit Betlem, *Civil Liability for Transfrontier Pollution: Dutch Environmental Tort Law in International Cases in the Light of Community Law*, at 487 (Springer, 1993).

^㉓ *Id.*, 485.

^㉔ *Id.*, 334.

1985年荷兰颁布了《土壤保护法》，建立起污染者预防和修复的行政义务体系。^{②5}此后，公法手段成为主要的土壤污染救济方式，改变了立法前主要依赖政府修复，再根据《民法典》向污染者求偿的做法。^{②6}《土壤保护法》还规定主管机关可以命令污染者，或污染地/结果发生地的所有者或长期承租者进行场址评估和采取修复措施。^{②7}在义务人不履行义务的情况下，行政机关可以采取行政强制措施，包括行政实施命令和附罚款的命令。^{②8}前者应说明如果相对人不履行命令，行政机关将采取行政代履行措施并就履行费用求偿。后者则是在相对人不履行命令的情况下课以罚款。^{②9}在政府采取措施的情况下，可以向污染者或受益者求偿其支出的费用。^{③0}

2007年，荷兰通过修改《环境管理法》对欧盟《指令》进行了转化，继受并强化了《指令》和土壤污染立法中公法主导的传统。《指令》对责任人课以就环境损害进行预防和修复的义务。主管机关可以命令相对人采取相应措施，也可以自行采取措施，再向责任人求偿。^{③1}但《指令》并没有规定政府求偿的具体方式是通过民事诉讼还是行政手段。不同于《土壤保护法》下政府通过民事诉讼向污染者和受益人求偿修复费用，《环境管理法》下的费用求偿是通过行政法下的强制支付命令来实现的。^{③2}

（二）私法主导下的生态损害救济

美国法下采取“自然资源损害”一词指代对环境本身带来的损害。普通法通过公共信托原则和国家亲权原则授予了州政府就部分自然资源损害起诉的权利。但该原则对涵盖的污染类型和授权的机构都有着较大限制。^{③3}此外，普通法的救济方式，包括赔偿金和禁令，都无法对自然资源损害进行充分救济。^{③4}

由于普通法的限制，自然资源损害的救济制度开始在制定法下发展起来。本文以CERCLA为例加以介绍。联邦环保局是CERCLA下的授权部门，根据国家反应计划采取相应的反应行动。若其认为设施的所有者或运营者是采取该措施的合适主体，也可以允许后者采取相应措施，进行救助调查和可行性研究。^{③5}此时政府并未对相对人课以义务。若反应行动不足以将受损的自然资源恢复到损害前的状况，则剩余的自然资源

^{②5} Zie Wet bodembescherming, art. 13.

^{②6} See Rik Mellenbergh, *Soil Protection Law and Reclaiming Soil Decontamination Costs in the Netherlands*, 3 J. Eur. Env. & Pla. L. 240, 241 (2006).

^{②7} Zie Wet Bodembescherming, art. 37, 43.

^{②8} Zie Wet Bodembescherming, art. 95.

^{②9} Zie Algemene Wet Bestuursrecht, art. 5:21, 5:31d.

^{③0} Zie Wet Bodembescherming, art. 75.

^{③1} See Environmental Liability Directive, art. 5, 6, 8.

^{③2} Zie Wet Milieubeheer, art. 17.16 (2); Algemene Wet Bestuursrecht, art. 4:114.

^{③3} See Kathleen Chandler Schmid, *The Depletion of the Superfund and Natural Resource Damages*, 16 NYU Env. L. J. 483, 488 (2008); Allan Kanner & Mary E. Ziegler, *Understanding and Protecting Natural Resources*, 17 Duke Envtl. L. & Poly F119, 129 (2005).

^{③4} See James Seevers Jr., *NOAA's New Natural Resource Damage Assessment Scheme: It's not About Collecting Money*, 53 Wash. & Lee L. Rev. 1513 (1996).

^{③5} See 42 U.S.C. § 9604.

损害由自然资源托管者^{③⑥}负责组织修复和求偿。托管者在自然资源损害评估中发挥着主导作用,而潜在责任方可以与托管者进行合作性评估或在评估完成后达成和解。^{③⑦}但潜在责任方并无进行合作性评估、参与制定修复计划或从事修复工作的义务。在其不配合的情形下,主管机关不能通过行政命令要求责任方采取行动,而只能自行行动后向之索赔。

美国法下普通公众或环保组织并非提起自然资源损害赔偿诉讼的主体。很多制定法都纳入了公民诉讼的授权条款。但就自然资源损害而言,公民和组织不能直接对责任人提起要求其进行评估与修复的诉讼请求,而只能在政府的调查评估、修复或赔偿资金使用不合法时,对政府提起诉讼。由于评估和修复自然资源损害耗时耗力,而政府资源有限,往往需要在不同的损害间进行权衡,选择最为紧要者进行评估和修复。故而立法对托管者的授权也十分广泛,公众通过公民诉讼迫使托管者采取修复措施的空间不大。^{③⑧}但这并不排除公众在普通法或州制定法框架下请求救济的权利。

(三) 荷兰与美国模式的差异及其原因

荷兰和美国的不同救济模式的形成主要受以下因素的影响:

第一,公民法主导模式的差异在大陆法下更具实际意义。大陆法系公民法划分较为严格,政府的行政行为和民事行为属性迥异,遵从不同的原则和程序。司法机关对两种行为的审查标准也有很大差异。普通法系下,公民法之间以及民事与行政诉讼之间都无严格的区分,故而在生态损害救济模式的选择上,普通法更为灵活。

第二,公法模式能否胜任生态损害的救济工作与行政机关的能力及法律传统密切相关。行政机关命令相对人采取预防和修复措施必须有法律的明确授权,受职责范围、正当程序、管辖范围等因素的制约。在没有授权的情况下,行政机关可能借由侵权法迂回地对生态损害进行救济。荷兰私法措施的使用以不对公权力的实施构成不当干涉为限。但美国并未构建起相应的公法义务体系,只能通过私法途径加以救济。除需要法律的授权之外,行政行为的实效也与其执行方式有关。荷兰法下,行政制裁是一项重要的保障环境法律执行的手段,行政机关对其采用可自行决定。^{③⑨}而在美国,相对人不执行行政命令时,行政机关进行强制执行或课以行政处罚的权限十分有限,往往需诉诸法院,由法院发布相应命令。^{④⑩}行政执行手段的弱势也与美国环境法的发展有关。随着风

^{③⑥} 包括联邦自然资源管理机构、各州州长委派的机构和印第安部族。现有的联邦托管机构包括农业部、商务部、国防部、能源部、内政部和其他被授权管理或保护自然资源的机构。

^{③⑦} See Valerie Ann Lee, P J Bridgen & Environment International Ltd., *The Natural Resource Damage Assessment Deskbook: A Legal and Technical Analysis* (Environmental Law Institute, 2002).

^{③⑧} See Peter Wetterstein, *Harm to the Environment; the Right to Compensation and the Assessment of Damages*, at 197 (Clarendon Press, 1997).

^{③⑨} See Michael G. Faure & Katarina Svatikova, *Criminal or Administrative Law to Protect the Environment, Evidence from Western Europe*, 24 J. Env. L. 254, 271 (2012).

^{④⑩} 参见王名扬:《美国行政法》,北京大学出版社2016年版,第397页。

险社会的到来,行政规制才开始补充侵权法和刑法进行风险的防控和救济。^{④①}迄今三种实施手段的力度也是从行政到民事、刑事手段不断递增的。民事手段(包括民事罚款)常用于较为复杂的、较少依赖于相对人合作的情形。行政手段则多用于快速解决简易案件。^{④②}自然资源损害的评估和修复较为复杂,在三种法律执行手段的选择中,民事手段相比行政手段更为适宜。

第三,美国 and 荷兰法下,通过私法手段解决生态损害救济的障碍不同。荷兰法侵权责任法下可赔偿损害的类型无法涵盖全部生态损害;其救济方式与生态修复也有着较大区别。大陆法的体系性使得突破这些限制以对生态损害进行侵权救济十分困难。普通法则更注重法律的实用性,而非体系的周延性。即使普通法对生态损害的救济存在障碍,也可以通过制定法的颁布来加以克服。故而美国法下并不存在对新型损害进行民事救济的体系性障碍。

第四,荷兰公法主导模式的形成还受到欧盟法的影响。《指令》的转化实施加强了荷兰模式的公法主导性。指令之所以使用“责任”这一具有私法指向的词语,是因为立法讨论之初,其试图协调成员国环境民事责任立法,包括人身和财产损害所致的责任。但协调成员国既有的侵权责任法过于困难,从而导致立法限定于对环境本身的损害的救济,并更多地关注公法义务。^{④③}在转化指令时,荷兰选择了强制支付命令,而非民事诉讼的方式来实现对政府修复费用的弥补,强化了公法的作用。

(四) 荷兰与美国模式的共同点

在上述差异之外,荷兰与美国模式也有一些重要的共通之处。

第一,行政机关在公私法主导的模式下都扮演着重要的角色。荷兰模式下,行政机关的重要性自不待言。即使在更多依赖司法干预的美国,行政机关也发挥着重要作用。虽然环保局和托管者不直接通过行政命令要求责任人采取反应行动或修复措施,但他们在启动措施、确定修复标准、拟定修复方案以及实施或监督实施方面都发挥着决定性作用。法院仅在行政机关与责任人就损害评估、修复行为存在争议的场合介入,从而避免了法院在确定修复方案、监督执行过程中专业性和能力不足带来的问题。

第二,其他主体在生态损害的救济中发挥着辅助作用,并不直接提起生态损害诉讼。美国自然资源损害的相关立法及普通法都仅赋予政府部门(及印第安部族)就自然资源损害求偿的权利,而未扩及环保组织及其他主体。《指令》下,环保组织等其他主体也仅有提出审查行政行为合法性的权利。^{④④}这样的构造,主要是因为生态损害评估和修复对专业性、经济能力都有着较高的要求,环保组织和个人往往难以承担。且要求法院承担认定和量化损害、决定修复方案、监督修复执行等重任也存在困难。此时,与其由

④① See Edward L. Glaeser & Andrei Shleifer, *The Rise of the Regulatory State*, 41 J. Econ. Literature 401, 401 (2003).

④② See Raymond W. Mushal, *Reflection upon American Environmental Enforcement Experience as It May Relate to Post-Hampton Development in England and Wales*, 19 J. Env. L. 201, 204 (2007).

④③ See Gerd Winter, Jan H. Hans & Richard Macrory et al, *supra* note 5, 163.

④④ See Environmental Liability Directive, art. 8.

环保组织和个人直接提起生态损害诉讼,不如通过对政府行为的监督、以普通侵权诉讼及民事公益诉讼作为补充更好地促进对生态损害的预防和救济。

三、我国生态损害救济模式的选择

我国生态损害救济的私法主导性甚至比美国更强。美国和荷兰模式下,相对行政机关,其他主体仅发挥着辅助作用。而我国环保组织和检察机关在提起生态损害诉讼方面比政府更为积极。审议中的《民法典侵权责任编》通过规定修复这一新型责任承担方式,明确赔偿范围,将生态损害责任纳入侵权责任框架,进一步强化了救济的私法特色。^{④5}然而实践中私法救济方式效果的不彰导致了对我国采取私法主导模式合理性的疑问。荷兰与美国模式的比较研究显示,救济模式的选择与不同法系对公私法划分的严格性、行政机关通过公法予以救济的能力以及侵权法的构造有关。我国在立法体系上更接近大陆法系,坚持公私法的划分,这使得模式的选择更具重要意义。下文分别从行政机关的权能和私法救济两方面分析我国采取两种模式的可能。在此基础上,通过比较克服两方面障碍的可行性为我国生态损害救济的模式选择提供借鉴。

(一) 行政机关的权能

若采取公法主导的生态损害救济模式,至少需要解决三个问题:责任人的修复义务,行政机关采取行政措施的权限、保障措施的有效性以及对相对人或公众权益的救济。

第一,《环境保护法》并未总括性地规定污染破坏者在发生环境污染或生态破坏时的修复义务。一些单行法律法规为公法手段救济提供了更多空间,如《水污染防治法》下的责令“停止违法行为,限期采取治理措施,消除污染”和代履行;^{④6}《水土保持法》下的责令采取退耕、恢复植被等补救措施、责令限期改正或限期治理等。^{④7}这些方式要求一定程度上修复被损害的环境,但未规定具体修复的标准、程序,也未规定修复期间生态服务功能损失或无法修复时的救济方式。且其多以出现特定违法行为时,以行政命令或行政处罚的形式出现。^{④8}如果未发生法定的违法行为,却产生生态损害,则无法启动救济程序。相对而言,《土壤污染防治法》在构建生态损害救济的公法机制方面走得更远。其对土地使用权人或土壤污染责任人设置了进行土壤及地下水污染状况调查、风险评估和修复的义务。生态环境主管部门可以要求义务人采取措施、评审风险评估报告、决

④5 参见《民法典侵权责任编》(草案三次审议稿)第1010、1011条,载北大法宝, http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=protocol&Gid=c75c2880e63792b87ad4f29dd97b1e82bdfb&keyword=民法典侵权责任 &EncodingName=&Search_Mode=accurate&Search_IsTitle=0,最后访问时间:2019年9月27日。

④6 参见《水污染防治法》第85、90、94条。

④7 参见《水土保持法》第49、51、52、56条。

④8 关于此类行为应被定性为行政处罚还是行政命令存在争议。参见涂永前:《环境行政处罚与环境行政命令的衔接——从〈环境保护法〉第60条切入》,载《法学论坛》2015年第6期;程雨燕:《试论责令改正环境违法行为之制度归属——兼评〈环境行政处罚办法〉第12条》,载《中国地质大学学报》(社会科学版)2012年第1期。

定风险管控措施的采取及对修复方案进行备案。^④在这样的规范之下,修复义务的课予不再局限于发生特定的违法行为的情形。

第二,目前环境法下的行政强制执行和行政处罚难以保障修复的实现。《行政强制法》确认了法院执行为主,行政机关执行为辅的强制执行模式。^⑤环境行政主管部门采取强制执行措施的权限仍然有限。这导致了实践中环保部门执行力缺乏,法院执行负担重,申请法院执行周期长等问题。^⑥部分法律规定,当违法者逾期未采取改正或治理措施时,行政机关可以指定他人代为履行,所需费用由违法者/责任人承担;^⑦或对其采取罚款、责令停业或关闭等行政处罚措施。^⑧自环保法修订以来,行政代履行作为一项解决环境义务履行不足问题的保障措施,日益受到重视。但其仍然存在着权利主体不明确、催告程序不统一、履行费用缴付缺乏保障等问题。^⑨此外,我国目前的行政处罚面临着财产罚额度低、声誉罚缺乏拘束力,行为罚适用少等问题。^⑩保障措施的局限性也限制了生态损害修复公法义务的实现。

第三,公法行为对相对人或公众权益造成损害时,是否存在有效的救济措施是另一个应当考察的重要问题。行政机关要求相对人采取的修复行为实际上是针对特定相对人课以义务的具体行政行为。当事人不履行义务时,政府组织或委托他人进行的修复则可纳入代履行的范畴。将政府行为纳入公法框架可为相对人和公益诉讼原告寻求救济提供基础。但由于我国未建立全面的生态损害救济义务体系,行政机关仅在有限的情形下可通过发布修复命令或采取代履行的方式进行救济。在其他未获授权情形下,行政机关往往并非发布修复命令,而是根据实际情况自行组织实施修复工作。此时,政府组织的修复工作并不旨在形成、变更当事人的权利义务,客观上也不具有法律效力,属于行政事实行为,而非行政法律行为。^⑪而事实行为仅在十分有限的范围内被纳入行政诉讼的受案范围。^⑫就行政机关直接组织实施的修复行为可能难以通过行政诉讼进行救济。此外,由于环保组织不具有提起行政公益诉讼的主体资格,其在不满意政府修复行动时,只能起诉污染者,绕开政府既有的修复行为寻求救济。

(二) 私法救济

^④ 参见《土壤污染防治法》第58-68条。

^⑤ 参见杨小军:《行政强制执行的主要制度》,载《法学杂志》2011年第11期;钱水苗、魏琪:《论环保非诉案件行政强制执行制度的完善》,载《法治研究》2013年第5期。

^⑥ 参见前引^⑤,钱水苗、魏琪文;严厚福:《环境行政处罚执行难中的司法因素:基于实证的分析》,载《中国地质大学学报》(社会科学版)2011年第6期。

^⑦ 例如《土壤污染防治法》第94条;《水污染防治法》第85、90、94条;《水土保持法》第56条;《森林法》第39、44条。

^⑧ 例如《土壤污染防治法》第95条;《固体废物污染环境防治法》第81条。

^⑨ 参见竺效、丁霖:《论环境行政代履行制度入〈环境保护法〉——以环境私权对环境公权的制衡为视角》,载《中国地质大学学报》(社会科学版)2014年第3期;唐绍均、蒋云飞:《环境行政代履行制度:优势、困境与完善》,载《中州学刊》2016年第1期。

^⑩ 参见汪劲主编:《环保法治三十年,我们成功了吗?》,北京大学出版社2011年版,第178页。

^⑪ 参见王锴:《论行政事实行为的界定》,载《法学家》2018年第4期。

^⑫ 例如《国家赔偿法》第3条第3、4项之规定。

我国《侵权责任法》未直接界定“损害”的范围,而是将侵权法的保护对象限定为民事权益。可救济的损害是侵犯民事权益的后果。考察生态损害能否纳入侵权法救济范畴则需厘清其侵犯的法益是否为侵权法保护的对象。此外,传统侵权法下的责任形式是否能为生态损害提供有效救济也应加以考察。

第一,为解决生态损害侵害法益的可私法救济性,常见途径为将相关主体采取的预防或修复措施费用转化为财产权益损失、引入环境权的概念或自然资源国家所有权学说。然而修复费用向财产损失转化无法解决环境无法修复时的损失及修复期间的生态环境功能损失的救济问题。为解决这一困境,有学说提出引入环境权的概念对生态损害进行救济。^⑤然而环境权的存在、内涵、法律属性本身仍存在着很大争论。^⑥更有学者认为,环境权的引入并没有创制出新型权利,实际上仍是以环境为媒介的人身、财产等传统民事权益,故对其的侵犯无法对应生态损害。^⑦将生态损害视为对自然资源国家所有权的侵犯也难以为其民法救济路径提供有力支撑。首先,学界对自然资源国家所有权的法律属性,尤其是其能否构成一项民事权利仍存在较大争议。其次,并非所有环境要素都能纳入所有权的范围,国家也非自然资源的唯一所有者。^⑧此外,即使将自然资源国家所有权视为民法上的财产权利,传统民法对于财产权利的救济方式也无法涵盖环境的生态价值。《民法典侵权责任编》虽然纳入了生态损害责任,但并未解释其理论基础。赞成者认为这是通过损害拟制条款,明确了生态损害的可侵权救济性,且生态损害为财产损害,^⑨或认为生态损害责任的原权为环境权。^⑩但亦有学者持反对态度,认为生态损害责任与环境侵权责任具有不同的法律性质,不应在民法典中规范。^⑪

利益通常被解释为有用性、好处、收益等,体现的是客体对主体的意义。^⑫探究生态损害是侵犯何种利益的后果,需要理解环境作为客体对主体人的意义。这可以从分析环境对人的价值入手。^⑬环境同时具有使用价值与非使用价值。非使用价值的核心为

⑤ 参见王宏:《论民法总则制定后环境权在民法典中的建构》,载《法学论坛》2017年第6期。

⑥ 参见朱谦:《论环境权的法律属性》,载《中国法学》2001年第3期;陈海嵩:《论程序性环境权》,载《华东政法大学学报》2015年第1期;张震:《环境权的请求权功能:从理论到实践》,载《当代法学》2015年第4期;汪劲:《进化中的环境法上的权利类型探析——以环境享有核心构造为中心》,载《上海大学学报(社会科学版)》2017年第2期。

⑦ 参见徐祥民、辛帅:《民事救济的环保功能有限性——再论环境侵权与环境侵害的关系》,载《法律科学》2016年第4期。

⑧ 参见梅宏、胡勇:《论行政机关提起生态环境损害赔偿诉讼的正当性与可行性》,载《重庆大学学报(社会科学版)》2017年第5期。

⑨ 参见李昊:《损害概念的变迁及类型建构——以民法典侵权责任编的编纂为视角》,载《法学》2019年第2期。

⑩ 参见侯国跃、刘玖林:《民法典绿色原则:何以可能以及如何展开》,载《求是学刊》2019年第1期。

⑪ 参见张新宝:《民法分则侵权责任编立法研究》,载《中国法学》2017年第3期;吕忠梅、窦海阳:《民法典“绿色化”与环境法典的调适》,载《中外法学》2018年第4期;刘超:《论“绿色原则”在民法典侵权责任编的制度展开》,载《法律科学》2018年第6期。

⑫ 参见韩卫平、黄锡生:《论“环境”的法律内涵为环境利益》,载《重庆理工大学学报(社会科学版)》2012年第12期;刘会齐:《环境利益论——从政治经济学视角分析》,复旦大学2009年博士学位论文(指导教师:严法善教授),第21页;徐祥民、朱雯:《环境利益的本质特征》,载《法学论坛》2014年第6期。

⑬ 虽然在伦理学意义上,不排除环境资源有其自身存在的意义以及对其他生物体和非生物体的功能。但能纳入法学调整范围的是通过环境所体现的人与人的社会关系。环境之所以受到法律这种手段的保护也在于其对人的价值。

“存在价值”,即除使用价值外的自然资源的价值,包括了选择价值(将环境资源保存为以后进行使用的价值)、替代价值(得知某一自然资源受到保护,可为他人使用的价值)、遗产价值(得知资源被保护以为后代使用的价值)和准选择价值(将自然资源用于未知用途的价值)。^{⑥7}由此可见,所谓存在价值仍是以使用为核心建立的对人的价值。只是这里的人不仅指向评价主体,还包括了不特定的其他人乃至未来世代。人们对环境资源的使用方式也具有多样性。这种使用是维持人的生命、健康的基础,也可以通过资源和资源产品表现为财产权。某些价值,如享受清洁、适宜的环境,优美景观的价值,在未对生命、健康权造成损害,而只是造成某种不适的情况下,无法归入法定的权利范畴。但这些价值仍体现了人的人格和财产利益,^{⑥8}不能一概排除侵权法的适用。其中某种利益是否受民法的保护以及其受保护的程度需要具体和细致的分析。故而生态损害对应着一系列不同种类的民事权益:人身权、财产权、人格利益和财产利益。其中有些受损权益的主体可能是特定的对象,是对私益的侵犯;有些权益则可能涉及到不特定的多数人,需要对公益进行救济。

第二,生态损害侵犯权益种类的多元性意味着对之救济的方式更为复杂。由于人身、财产权外的其他利益不具有典型公开性,识别哪些主体的哪些利益受到影响则是一个难题。此外它们还面临着是否受到侵权法保护和需满足何种条件才能被保护的问题。即使这些利益受到保护,如何予以救济也面临着挑战。首先,这些利益往往对应环境的非消费价值乃至非使用价值,很难包含在市场价值之中。其量化需要通过采取修复、替代性修复措施或条件价值评估等其他方法来实现。至于采取其他责任形式,完整救济这些利益所要达成的程度和具体方式相对更难判断。如清理污染到何种程度,才能算是对舒适、审美等利益的停止侵害和排除妨碍并非显而易见。实现上述救济应采取停止排放污染物、转移污染介质、原地治理还是封闭污染物的手段也并不清晰。^{⑥9}恢复原状则是指将当事人之间的关系恢复到物理状态或价值层面上的原状。^{⑦0}适用恢复原状这一救济方式时,恢复环境经济状态的原样无法弥补非财产利益的损失;而由于环境是一个动态平衡的过程,恢复物理状态的原样也是不可能的。司法解释将生态环境修复解释为恢复原状的一种表现形式。^{⑦1}但学者们通常认为,鉴于救济对象、权益和范围、修

^{⑥7} See Frank B. Cross, *Natural Resource Damage Valuation*, 42 Vand. L. Rev. 269, 285. (1989).

^{⑥8} 如舒适性、安宁、审美可以为人格利益的一种体现。而景观利益还可能通过景观所附着的财产利益得到一定的体现。参见张宝、窦海阳:《环境侵权案件的逻辑与经验》,载吕忠梅等著:《中国环境司法报告(2015-2017)》,人民法院出版社2017年版;前引^{⑥0},徐祥民、辛帅文。

^{⑥9} 参见前引^{⑦1},巩固文。

^{⑦0} 参见崔建远:《关于恢复原状、返还财产的辨析》,载《当代法学》2005年第1期。

^{⑦1} 最高人民法院《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(法释[2015]1号)第20条第1款规定:“原告请求恢复原状的,人民法院可以依法判决被告将生态环境修复到损害发生之前的状态和功能”;最高人民法院《关于审理环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释[2015]12号)第14条规定,被侵权人请求恢复原状的,人民法院可以依法裁判污染者承担环境修复责任。

复标准、方式等方面的差异,二者具有不可替代性。^②

(三) 克服两类障碍的可行性

不论是构建公法还是私法主导的生态损害救济体系,都存在着一定的障碍。模式选择的关键在于分析上述何种障碍可以通过立法的修订和实践的改进加以克服,何种障碍更为体系性和根本性而难以解决。

第一,侵权责任法的适用范围、责任构成的基本要求和救济方式都涉及其制度建立的根本,重构起来十分困难。生态损害的救济需要识别受损主体、被侵犯权益的类型,并据之确定权益受侵权法保护的度以及公私益不同的救济方式。既然如此,能否通过引入“生态损害”的概念,总括性地将受到影响的权益纳入侵权法的保护范围,并通过“生态修复”或界定损害赔偿的范围来进行救济,从而避免一一识别利益和分别救济的难题?亦或建立独立于传统侵权法的生态损害责任?首先,我国在法律体系上更接近大陆法系,注重法律体系的完整性和逻辑的严密性。《民法典侵权责任编》固然可以通过纳入生态损害赔偿的责任方式来推进私法救济体系的建设,但在传统侵权框架下纳入性质相左的生态损害责任,还涉及到生态环境损害和民事权益的界定、救济方式的更新以及相应的程序规则设计,需要整个法律体系的协调,带来巨大的制度变迁成本。即使将生态损害解释为对不同种类民事权益的侵害以与民法对接,但其同时涉及对公益和私益的侵犯。而传统民事诉讼对公益、私益的救济采取不同的程序。如何创制新的诉讼程序,以统合对不同利益的救济并非易事。此外,生态损害的量化、生态修复与传统民事救济方式的对接也存在困难。其次,《民法典侵权责任编》的编纂本身并不能解决对生态损害进行救济的理论障碍,如生态损害属于何种性质的损害、所侵害的是何种权益、能否通过侵权法进行保护等。虽有观点认为可通过损害拟制条款,将生态损害纳入可获侵权救济的损害类型,但该观点又同时认为生态损害侵害的为环境权益,不同于传统民事权益。^③环境权和自然资源所有权作为生态损害的原权各有障碍。而且民法保护范围的扩张与其能否为新的权益提供有效保护密切相关。现代社会中,扩张中的侵权法在保护范围上仍是有边界的,需要在受害人的权益保护和民事主体的行为自由之间进行平衡,亦需考察侵权法与其他替代性制度的关系及社会经济发展、伦理道德观念等因素的影响。^④基于是否具有典型公开性及行为人对造成影响的可预见性,侵权法对不同种类的权利和利益保护的周延程度也存在着差异。^⑤即使将生态损害纳入侵权法的

② 参见前引⑨,吕忠梅、窦海阳文;李挚萍:《环境修复的司法裁量》,载《中国地质大学学报》(社会科学版)2014年第4期;侯佳儒:《生态环境损害的赔偿、移转与预防:从私法到公法》,载《法学论坛》2017年第3期;吴鹏:《最高法院司法解释对生态修复制度的误解与纠正》,载《中国地质大学学报》(社会科学版)2015年第4期。

③ 参见前引⑫,李昊文。

④ 参见龙著华:《论侵权法保护的利益》,载《法商研究》2007年第4期;朱虎:《侵权法中的法益区分保护:思想与技术》,载《比较法研究》2015年第5期。

⑤ 参见张志坡:《认真对待侵权法的保护范围——侵权责任法第2条之得失与改进方向》,载《苏州大学学报》(法学版)2016年第4期;葛云松:《〈侵权责任法〉保护的民事权益》,载《中国法学》2010年第3期;王利明:《侵权法一般条款的保护范围》,载《法学家》2009年第3期。

保护范围,侵权法对其能提供的保护程度也较弱:生态损害量化困难,具有主观性。其涉及受侵犯的权益,除人身和财产权利之外,其他利益,如舒适性、审美方面的利益不具备传统权利的归属、排他效能和典型公开性。^⑥这样的情形下扩张民法适用范围,生态损害仍缺乏明确性,潜在侵害者就其行为对生态损害的影响也缺乏可预期性,再加上分散的受害者缺乏足够求偿意愿,都会减损侵权法在救济生态损害方面的效果。最后,即使通过《民法典侵权责任编》的制定将民法的适用范围扩张至生态损害赔偿,或者建立独立的生态损害责任,也无法克服侵权法或类似构造的生态损害责任在救济生态损害方面的固有障碍。法院缺乏专业性和能力的困境以及司法救济中举证难、执行难和赔偿金额低等问题仍需解决。

第二,生态损害的救济具有重要的公益维度。而传统的私法规范是在解决私益纠纷的基础上建立起来的,需要重大改造才能适应公益保护的需求。行政权行使的一项重要目的就是执行公意,保护由之产生的公共利益。故而预防和救济生态损害本就是环境行政的一项重要职能。诚然,公法模式的建立也需要解决政府做出预防和修复命令的权限、命令的执行及公权力监督等问题。就权限问题,未来立法的修订可以借鉴《土壤污染防治法》的规定,构建全面的预防和修复的义务体系,使行政机关获得更广泛的发布修复命令的职权。在保障修复命令的执行方面,相对于美国,我国环境保护管理机关有更广泛的课以行政处罚的权限。且近年来行政机关采取行政处罚和行政强制的能力也呈强化趋势。尤其是修订后的《环境保护法》致力于构建严厉的制度体系,解决企业“环境违法成本低、守法成本高”的问题。立法授予了环境执法机构更广泛的监管权力,如环境监察机构的现场检查权、环保部门的查封扣押权,规范按日连续处罚、引入治安拘留处罚等等。^⑦按日计罚的增加适用对企业产生了更强的威慑力,并在部分地区起到了促进环境守法的效果。^⑧新法实施后,对违法、犯罪案件的移送措施适用频繁,行政拘留的采用也发挥了较好效果。^⑨民事、行政和刑事手段都是保障环境法律执行的重要方式。美国行政机关权限和执行能力较弱,在面对较为复杂的环境问题时,民事制裁为环境法的实施提供了重要保障。而我国民事制裁的使用范围、强度远不及美国,无法替代行政手段为环境法的执行提供强有力的保障。尽管学界对我国环境刑法是否具有行政附属性存在争议,但司法实践中常以此为指导,使刑法难以成为一项独立于行政手段的环境治理方式。^⑩故而在我国环境治理中,行政手段具有重要地位。仅因行政强制执行和行政处罚措施目前力度不足而忽视行政机关作为环境监管者和公益保障者的职

^⑥ 有学者认为,这些特点是区分权利与利益的重要因素。参见张力:《权利、法益区分保护及其在民法总则中的体现——评〈民法总则(草案)〉第五章》,载《河南社会科学》2016年第11期。

^⑦ 参见吕忠梅:《〈环境保护法〉的前世今生》,载《政法论丛》2014年第5期。

^⑧ 参见严厚福:《〈环境保护法〉“按日计罚”条款评析》,载《清华法治论衡》2015年第1期。

^⑨ 参见竺效:《环保重罚措施对法律实施的影响》,载《中国高校社会科学》2016年第4期。

^⑩ 参见赵星:《环境犯罪的行政从属性之批判》,载《法学评论》2012年第5期;庄乾龙:《环境刑法定性之行政从属性——兼评〈两高关于污染环境犯罪解释〉》,载《中国地质大学学报(社会科学版)》2015年第4期;柴云乐:《污染环境罪行政从属性的三重批判——兼论刑法对污染环境行为的提前规制》,载《政治与法律》2018年第7期。

能,转化其身份为原告,会导致“行政职权民事化、审判职权行政化”。^⑩就公法行为的救济而言,在明确政府发布预防和修复命令的权限之后,该行为可纳入具体行政行为的范畴,从而通过行政诉讼加以监督。将来建立起多元主体参与、涵盖多种修复行为的行政公益诉讼制度主要需要原告资格的扩张及受案范围向事实行为的拓展。在环保组织已经获得民事公益诉讼起诉资格并积累大量诉讼经验、部分事实行为已被纳入行政诉讼受案范围的基础上,这样的制度构建并不存在体系化的障碍。

综合以上分析可知,我国生态损害救济制度的建立应采取公法主导的方式,着重明晰环境主管机关的权限、强化行政执法能力并完善行政公益诉讼。私法手段则可对生态损害的公法救济提供补充。

四、我国生态损害救济制度的完善

为构建以公法为主导,私法为补充的生态损害救济模式,我国未来制度的完善可以从以下角度入手:

(一) 修复义务和行政机关权限的确定

为克服单行法零星救济的弊端,我国未来可通过修订《环境保护法》或制定专门的生态修复法来建立综合性的生态损害预防和修复的义务体系。行政程序的启动不应局限于相对人实施了违法行为的场合,而应考察行为对环境产生风险或损害的程度。立法应建立相应的启动标准、损害评估方法、修复标准和程序以及修复的执行、监督和修复后管理等规范。我国的立法和实践已经认可了一系列可赔偿的费用,并建立了一些相关评估标准和修复导则。很多规则虽然是为诉讼制度建立的,但也可作为公法援引或为公法框架下相应规范的细化和标准的建立提供借鉴。如在公法下建立修复义务时应应对修复作广义的界定,纳入无法直接修复时采取的措施,以利于前期行政监管手段与后期费用索赔的衔接。有观点认为通过公法手段来矫正违法和填补损害应限于采取直接修复活动的情形。如果损害无从、难以或不能(完全)修复,则公法手段无法适用,而应通过政府索赔权来予以救济。^⑪这种狭义的修复界定方式会大大限缩公法手段的适用范围,使得公私法救济方式并行,导致行政和司法资源的浪费。

(二) 行政执法能力的强化

在公法框架下,行政义务的实现需要得到保障。在将来立法中,可适当扩大环保部门的强制执行权,在立法中明确其就修复义务的实现采取行政强制措施的种类和程序。为克服代履行规定碎片化带来的问题,应将其适用扩大至所有环境污染和生态破坏问题,并在综合性立法中规范其适用规则,包括统一代履行主体、程序和费用保障,建立代

^⑩ 参见张宝:《生态环境损害政府索赔权与监管权的适用关系辨析》,载《法学论坛》2017年第3期。

^⑪ 参见前引^⑩,张宝文。

履行基金的私法债权求偿与公法债权征收相结合的费用承担方式等。^③ 还可通过建立委托强制执行机制和协助强制执行机制、探索建立重大案件行政强制先予执行机制等来强化行政强制执行的能力。^④ 在行政处罚方面,应明确修复义务人不履行义务时,环保机构可采取的行政处罚措施,并完善现有行政处罚方式。例如,对于罚款,应明确其罚基的设立以违法所得和违法情节为基础。^⑤ 同时构建多元化的行政处罚体系,保障修复义务的实现。

(三) 环境行政公益诉讼的完善

严格限制行政公益诉讼起诉资格的弊端已经暴露。今后的立法中,应放宽行政公益诉讼的主体资格限制,授权环保组织提起诉讼,以避免其借道民事诉讼对行政机关行为进行监督。

但在何种程度上,环保组织或检察机关可以就行政机关在启动修复工作中的不作为为提起诉讼值得进一步思考。生态损害的修复往往周期长、费用高昂,而行政机关的人力财力都有限,不得不考量启动公法救济程序的成本效益,在大量的损害中作出优先级的排序。授权对政府所有不作为的情形提起行政公益诉讼,无异于剥夺了行政机关的裁量权,由司法机关替代行政机关在诸多执法事项中作出优先排序,可能导致修复资源分配的无效率。在我国未来制度构建中,考察行政机关不作为的可审查性时,应细致衡量环境保护和修复资源高效分配的需求,并平衡合法行政的要求与行政机关的自由裁量权。例如通过立法明确行政机关在决定是否要求相对人或自行组织实施修复工作以及采取何种修复措施时应予考察的标准。

此外,行政机关直接自行组织实施的修复工作作为行政事实行为,也应纳入司法审查的范围。随着现代国家给付行政与服务行政的发展,大量事实行为出现,实践中也可能会对相对人的权利义务造成影响,从而产生救济的必要。^⑥ 行政机关自行组织实施的修复行为虽然没有指向具体的相对人,但其实施可能会对修复义务人乃至公众的权益造成影响。在修复完成后,行政机关可就其采取措施的费用向修复义务人索赔。对于公众而言,如果修复行为不足以消除污染造成的健康、生态风险,其环境权益仍然可能处于受到威胁的紧迫状态。赋予环保团体、检察机关就这类行为提起行政公益诉讼的资格,并允许其就不充分的修复行为提起确认违法和要求充分修复的给付之诉,可以在公法框架内就修复行为的合法性和充分性进行考察,发挥行政机关的主动性和积极性。否则,相关主体只能提起民事公益诉讼,将行政机关主导的修复与法院的判决置于潜在冲突之中。

③ 参见前引⑤,竺效、丁霖文。

④ 参见前引⑤,钱水苗、魏琪文。

⑤ 参见程雨燕:《环境罚款数额设定的立法研究》,载《法商研究》2008年第1期;徐以祥、梁忠:《论环境罚款数额的确定》,载《法学评论》2014年第6期。

⑥ 参见王锡锌、邓淑珠:《行政事实行为再认识》,载《行政法学研究》2001年第3期;汪应明、李清伟:《论行政事实行为的法律规制》,载《求索》2011年第9期。

(四) 生态损害诉讼的配套和补充作用

公法手段虽然在对生态损害的救济中发挥主导作用,但其适用仍存在限制。第一,行政机关自行采取修复措施之后,需要就费用进行求偿。代履行费用的承担可通过行政程序执行。其他情形下,生态损害诉讼可作为公法手段的配套措施,促使污染者付费原则的实现。第二,当公法手段的适用受到限制时,可通过民事诉讼予以补充。由于公法体系的完善尚待时日,行政机关在没有获得明确授权时,侵权法仍可起到补白作用。此外,公法下行政机关的履职行为要符合一系列的形式和程序条件,如管辖权的规定。对于域外或跨行政区域公民或法人行为导致的环境污染,直接行使行政权力困难,行政机关可以平等主体身份提起生态损害诉讼。第三,当出现前述行政机关无法行使行政权,只能请求民事救济的情形时,由于诉讼行为不属于行使行政职权的范畴,无法涵盖在行政诉讼受案范围内。行政机关不提起诉讼时,应允许环保组织、检察机关对污染者提起民事公益诉讼。此外,民事公益诉讼不仅可对损害进行事后救济,也可以表现为预防性诉讼。当一事件有导致生态损害发生之虞,也可能对不特定多数人的身、财产权利造成威胁。此时,将环保组织、检察机关的作用限定于向主管机关检举、发出检察建议,并以不作为之诉加以保障,很可能无法及时救济具有重大、紧迫威胁的损害。而民事公益诉讼直接针对污染者的危害行为,且存在先于执行的机制,可更为及时地防止损害发生。

结 语

围绕着环境公益诉讼和政府索赔权,我国建立了私法主导的生态损害救济体系,而忽视了公法救济制度的建立和运用。在各异的法律传统和制度背景下,各国在生态损害救济体系的模式构建上选择了不同的道路,展现出不同的制度设计和程序安排。公私法主导救济模式的根本差异在于行政与司法干预的不同比重,以及行政主体与其他主体在程序运行中的不同作用。换言之,生态损害救济的模式选择还涉及到环境多元共治体系下不同主体的角色定位以及环境治理中行政权与司法权的关系。公法主导的救济模式更强调行政机关在环境治理中的主导地位;私法主导模式下公众参与、司法监督的作用则更为显著。

值得注意的是,模式区分的意义也不能绝对化。公私法主导的救济模式在构造上也呈现出很多相似之处。即使是作为公法救济模式代表的欧盟《指令》,也被认为是混合有公、私法的特色,建立在公法性质、私法操作的请求权基础上。^⑩正因如此,我国在经验借鉴过程中,更多关注了欧美救济模式中私法的特色,而忽视了公法手段的作用。对欧美救济模式的比较分析显示,即使私法模式下司法权和私主体的作用更加显著,但制

^⑩ 参见[德]克里斯蒂安·冯·巴尔:《大规模侵权损害赔偿责任的改革》,贺栩栩译,中国法制出版社2012年版,第83页。



度构建中也应充分发挥行政机关的专业性与能动性,私主体与司法权的补充作用应有其边界。这与我国生态损害救济制度中体现的环保组织和检察机关积极推进,行政机关消极卸责,以及行政职权民事化、司法职权行政化形成鲜明对比。

此外,对救济模式的探讨不仅有助于生态损害救济实践困境的解决和具体制度的完善,对环境治理体系的研究和公益诉讼制度的发展也具有重要意义。强调公法手段在救济生态损害中的主导地位意味着即使在大力推进环境多元共治的今天,行政机关也不能消极卸责。为监督公法救济措施的合法运行,应将公益诉讼发展的重心从民事公益诉讼转向行政公益诉讼。而私法手段的补充作用则意味着生态损害修复与赔偿诉讼应在民事公益诉讼中退居辅助地位。民事公益诉讼事前的预防功能,以及对其他损害不特定多数人民事权益行为的震慑和救济功能应予以加强。

Abstract: Based on environmental public interest litigation and the governmental right of claim, a private law oriented regime for ecological damage relief has been established in China. On one hand, this regime has promoted the development of environmental rule of law. On the other hand, it has caused problems such as the mismatching roles between stakeholders, the lack of link between administrative activities and judgments, as well as the limited capacity of courts in deciding and supervising remediation. Less attention has been paid to the public law approach in ecological damage relief in current legislative framework. Based on the comparative study of Dutch and American systems, this article summarizes the factors influencing the choice between public and private law approach: the influence of legal systems on the division between public and private law, the authority and capacity of administrative agencies in remediating ecological damage as well as the difficulties for private law to accommodate this new type of damage. Considering China's characteristics in these aspects, this article proposes to establish a public law-oriented relief regime via legislative authorization, strengthening administrative capacity and improving the administrative public interest litigation regime. Private law approach can play a supplementary role before public law obligations are imposed or are not applicable.

(责任编辑:陈贻健)

